

1500135-95.2019.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... de biqueiras. Lá é local de intenso tráfico de drogas. As crianças ficam um pouco mais para dentro. O que fica para o lado de fora é um pátio que fica ao lado do local onde é usado como biqueira. Acredita que não havia crianças ali na hora. Acha que o Wellington foi preso posteriormente por tráfico de drogas, mas não se recorda direito. Não sabe se o celular dele foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo - SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500135-95.2019.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500135-95.2019.8.26.0575

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS EDUARDO ARMANDO CAMILLO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal contra Lucas Eduardo Armando Camillo e Wellington Donizeti

Porto da Silva eis que no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 10 horas, na Rua das Mangueiras, Carlos Cassucci, nesta cidade e comarca, traziam consigo e guardavam, nas imediações de estabelecimento de ensino (escola CAIC), 41 (quarenta e um) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 23,90 gramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 23/25), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de pgs. 171/173 veio instruída com os documentos de pgs. 01/170.

Notificação determinada pela decisão de pgs. 174/175.

Wellington Donizeti Porto da Silva apresentou resposta preliminar nas pgs. 223/234 alegando inépcia da denúncia. Alega falta de provas de conduta prevista no tipo penal imputado na denúncia. Teceu considerações sobre o conteúdo da filmagem e que não é possível concluir que o celular seja de propriedade do réu. Argumenta que não há perícia nos autos confirmando a localização de fotos ou qualquer outro arquivo vinculando o réu ao local em que o entorpecente foi encontrado. Indica incongruência na versão dos policiais e alega que não há nenhum elemento de prova nos autos capaz de vincular o acusado com o entorpecente. Refuta a causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da lei de drogas, pois não há provas de que a escola estivesse funcionando e que o local da escola é distante do ponto em que ocorreu a apreensão do entorpecente. Requereu o desentranhamento do relatório de pgs. 158, exclusão da majorante e absolvição, acrescentando as fotografias de pgs. 235/258.

Lucas Eduardo Armando Camilo apresentou sua defesa preliminar nas pgs. 260/266 alegando insuficiência de provas e destacando que no horário da abordagem não é crível que inexistisse outra pessoa no local que pudesse servir de testemunha "fedatária". Alega que a acusação parte de responsabilidade penal objetiva e que à míngua de testemunhas a conduta deve ser desclassificada para os moldes do art. 28 da lei de drogas ou deve ser absolvido o réu. Acrescentou os documentos de pgs. 267/278.

Pela decisão de pgs. 307/309 foi recebida a denúncia aos 29 de novembro de 2021, designando-se audiência de instrução para 26 de janeiro de 2022.

Na data supra foi realizada audiência de instrução, conforme termo de audiência de pgs. 368/369.

Memoriais ministeriais nas pgs. 381/386 requerendo a parcial procedência da ação penal. Em suma, pugna pela condenação dos réus após abordagem das provas coligidas, afastando-se apenas a majorante.

Memoriais do réu Wellington nas pgs. 415/425 indicando confusão no depoimento dos policiais e que não há provas de que o telefone apreendido pertença ao réu. Refuta novamente a causa de aumento de pena, pois a escola não estaria em funcionamento no dia 24.01.2019. Torna à carga do quanto alegado em resposta preliminar no sentido de que o Núcleo de Perícias Criminais de Americana encaminhou apenas a extração parcial dos dados através de mídia lacrada e arquivo executável para a perita solicitante, Milla Marques Hermidorff da EPC de São João da Boa Vista. Diante de tal informação não é possível afirmar que as imagens constantes do relatório de fls.158 tenham sido obtidas do material contido no Relatório de Análise nº 301.528/2020, fls.145 a

147, de modo que o relatório de pgs. 158 não pode ser equiparado a qualquer documento pericial e que a testemunha João Carlos indicou que o celular foi encontrado em posse de Lucas. Alega que o único indicio de que o réu poderia ter alguma ligação com a droga apreendida seria a localização do seu celular no local dos fatos e que não há provas de que o celular pertença a Wellington. Requer a

improcedência da ação ou afastamento da causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas.

Nas pgs. 442/447 encontram-se os memoriais do réu Lucas que sustenta, em síntese, a falta de provas de traficância, sendo o réu drogadito que esteve internado em outra ocasião. Quanto ao telefone apreendido sustenta que isso não comprova a verdade, ao passo que Lucas estava no local dos fatos porque é mero usuário. A droga apreendida não pode ser vinculada aos réus. Pugna pela desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da lei de drogas, concedendo o devido tratamento ao réu Lucas.

DECIDO.

1 - DAS PROVAS DE MATERIALIDADE

A materialidade delitiva está amparada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, pelo auto de constatação preliminar de fls. 09/10. Comprovante de depósito de pgs. 21 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 23/25, demonstrando a apreensão de 23.9 gramas de cocaína e laudo de pgs. 140/148.

2 - DAS PROVAS DA AUTORIA

Tiago Henrique Pisa recorda-se que estavam fazendo diligências de viatura e estavam próximo ao "Colorido", predinhos do Profast e visualizaram os réus parados na calçada e saíram correndo. Foram ao local e encontraram 2 pinos de cocaína do lado da moto. O policial João viu o Lucas jogando. Havia uma garrafa de danone numa lixeira e ela estava camuflada no lixo e havia mais pinos de cocaína. Na calçada, um lugar cimentado, estava o celular do Wellington. Havia foto dele na capa do celular. A moto parada na frente da lixeira pertencia ao Lucas. Apresentaram tudo na delegacia. Não conhecia os réus quando os visualizou. Confirmou a identificação posteriormente pela propriedade da moto e celular. O policial João reconhecia os dois. As diligências nas imediações dos predinhos eram para cumprimento de alguma ordem de serviço ou patrulhamento de biqueiras. Lá é local de intenso tráfico de drogas. As crianças ficam um pouco mais para dentro. O que fica para o lado de fora é um pátio que fica ao lado do local onde é usado como biqueira. Acredita que não havia crianças ali na hora. Acha que o Wellington foi preso posteriormente por tráfico de drogas, mas não se recorda direito. Não sabe se o celular dele foi periciado. Não tem conhecimento se os réus ficavam naquela biqueira de forma reiterada. Havia denúncia de que eles estavam envolvidos no tráfico, mas apenas o João Mancuso sabia. O local da prisão é muito próximo ao prédio da escola. O prédio onde ficam as crianças é que fica um pouco mais distante, cerca de uma quadra de futebol de distância. A parte que eles ficam é na lateral da escola. A lateral é cercada e geralmente eles não são vistos. Não reparou em mais ninguém na ordem da abordagem. Não deu para ver se eles estavam comercializando a droga naquele momento. O celular ficou no chão. Não pode afirmar se o celular foi dispensado ou se já estava no chão. Não viu dispensando. Não se recorda do relatório de pgs. 158.

João Carlos Mancuso recorda-se exatamente dos fatos. O local é conhecido como biqueira do Profast e os réus estavam bem próximos da escola Caic. A movimentação de usuários é intensa. Eles se assustaram. Lucas abandonou a motocicleta e abandonaram a droga. Fugiu junto com o parceiro Wellington. Apreenderam a motocicleta. O endereço de residência do réu Lucas era no bairro Colina São José. Lucas deixou um celular caído no chão e também dinheiro. Visualizaram movimentação de traficância intensa. Ali é um entra e sai constante, mais a agravante de estar próximo a escola. Não se lembra se estava havendo aula nesse dia. Sabe que é uma escola e eles estavam traficando bem próximo à escola. Ambos são conhecidos dos meios policiais. O Wellington principalmente. Ambos eram conhecidos por traficância. O entorpecente apreendido foi dispensado pelo Lucas que deixou 2 pinos

e o resto numa garrafa, dentro de uma lixeira. Do alambrado da escola os réus estavam a uns 4 metros. Os alunos ficavam nesta distância. Eles foram presos ao lado do alambrado. No momento que foram avistados havia gente perto deles, com certeza. Confirma esse relato. O celular estava ao lado da moto, jogado ao chão. Não se recorda de ter visto Lucas dispensando o celular, mas pertence a ele o celular e a moto.

Maria Clarice Martins de Carvalho não sabe nada sobre os fatos. Conhece o Lucas. É amiga da família dele há muitos. Frequenta a casa da família dele. Não conhece o Wellington. Não sabe dizer o que Lucas estava fazendo na rua das Mangueiras. Não mora perto da rua das Mangueiras. Lucas mora no Cassucci. Lucas mora para baixo da escola CAIC. Lucas é usuário de drogas e deu muito trabalho para a família dele. Ficou internado em Americana por 3 meses, mas agora está bem, está registrado e trabalhando. Não sabe que tipo de droga ele usa. Ele está trabalhando no barracão de verdura no sítio novo. A moto apreendida foi a avó dele que comprou para ele. Ela recebe uma pensão do marido e foi pagando as prestações da moto.

Lucas Eduardo Camilo, 24 anos. Nunca foi preso ou processado. É auxiliar de embalagem de verduras. Mora com sua mãe. Estudou até o segundo colegial. Usa maconha. Ouviu o que os policiais disseram, mas não compreendeu. Estava em casa. Saiu 7:50, muito nervoso porque estava desempregado e morando com sua mãe. Fazia um ano que estava limpo. Tinha vindo de uma internação de seis meses. Recaiu e foi buscar a droga. Quando parou a moto viu os policiais. Ficou com medo e abandonou a moto. Um já estava com o fuzil para fora e lhe apontou. Não estava fazendo nada. Não dispensou nada. Não tinha nem visto os moleques ainda. Estava muito nervoso com a situação. Não viu o Wellington lá. Nunca viu ele, não é amigo dele. Não tem nenhum problema com os policiais. Nunca foi abordado por eles. Nada sabe sobre o celular. Não foi apreendido celular de sua propriedade. Trabalhava de garçom antes da internação. Ganhava R\$ 100,00. A moto foi presente da sua avó. Ela quem lhe deu.

Wellington Donizeti Porto da Silva, 22 anos. Estava trabalhando na lenha com seu sogro. Estudou o ensino médio completo. Foi preso anteriormente por tráfico em 2019. Fazia 9 meses que estava em liberdade. Quando era menor não teve problemas. Morava com sua mãe e seu irmão de 10 anos, menor. Ouviu o que os policiais disseram e tem outra versão. Nem sabe o que está acontecendo. Estava num churrasco com sua família e tinha brigado com sua esposa. Sabe que os prédios são ponto de tráfico. Morava lá. Queria sair de lá, mas não tinha condições. Estava em dinheiro e já tinha gastado no churrasco. Deu o celular para um menino lá e ele lhe deu uma quantidade de maconha. Não conhece o Lucas e não tinha contato com ele. Não correu e nem estava no local dos fatos. Não tinha contato com o Lucas e apenas levou o celular lá e pegou droga para fumar. Morava lá, por isso tem fotos suas no local. O celular foi entregue em troca de um pedaço de maconha de cerca de 27 gramas. Não viu o Lucas lá quando foi comprar a maconha. Entregou o celular para um menino. Nunca teve problemas com os policiais Tiago ou Mancuso. Nada mais tem a declarar.

3 -) DA VALORAÇÃO CRÍTICA PROBATÓRIA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros

indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

Ambos os policiais foram uníssomos em dizer que patrulhavam pelo local conhecido como ponto de vendas de drogas e avistaram os réus juntos sendo que Lucas dispensou as drogas apreendidas.

A defesa ressenete-se por certas imprecisões nos depoimentos dos policiais. Todavia, natural que após 3 anos dos fatos alguma informação não esteja tão clara aos agentes públicos, o que não significa que estejam simplesmente elucubrando versão fantasiosa incorrendo em criminosa denúncia caluniosa. A presunção de inocência também resguarda os policiais, vale lembrar.

Assim, nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 41 eppendorfs de cocaína

para indevidamente "forjar" cidadãos, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoas com as quais não mantêm qualquer desafio ou problema pessoal. Ambos os réus declaram-se usuários de maconha, de modo que não pode ser agasalhada a tese de desclassificação para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que a substância sobre a qual mantinham a posse era cocaína, droga que não consumiam. Destarte, não há sequer alegação autodefensiva capaz de respaldar a hipótese de posse para uso exclusivamente pessoal.

No que se refere ao documento de pgs. 158, impugnado pela defesa por não se tratar de prova pericial, tem-se que os documentos também são meios de prova plenamente admitidos no processo penal, conforme disposições dos artigos 231 usque 238 do Estatuto de Ritos.

Dispõe o artigo 232 que consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

Como sabido, no sistema processual penal brasileiro não há hierarquia entre os meios de prova, sendo lícito que o julgador analise o caso orientado por seu livre convencimento motivado, tal como preconiza o artigo 155 do CPP.

Nesse diapasão, o documento de pgs. 158 refere-se a extração parcial de dados do aparelho celular de Wellington no ponto de vendas de drogas onde foi avistado pelos policiais civis na ocasião da denúncia. O relatório ainda destaca que o réu teve outras duas ocorrências no mesmo local e foi indiciado por tráfico de drogas em outro procedimento.

O panorama evidenciado pela prova coligida é que ambos os réus estavam juntos na biqueira, Lucas dispensou a droga, ambos fugiram juntos.

Indiferente a quem pertence o celular. Mesmo que pertença a Lucas, segundo o policial aposentado João Carlos Mancuso, as fotografias de pgs. 158 indicariam, neste outro cenário, o vínculo entre Lucas e Wellington, sendo que aquele inclusive guardaria fotos do parceiro em seu próprio aparelho de telefone.

Também não se pode olvidar que a propriedade de coisas móveis presume-se pela posse. Destarte, o celular apreendido não pode pertencer a terceiro não identificado, mas sim a um dos dois réus deste processo. Tal fato, aliado a todo o contexto, corrobora a versão dos policiais civis e sustenta a tese acusatória.

Como precisamente ponderado pelo Ministério Público nas pgs. 383/384: "Ainda que o policial Tiago tenha concluído que eram os acusados que estavam no local dos fatos a partir da pesquisa da propriedade da motocicleta ali abandonada e da identificação do proprietário do celular ali também encontrado, é certo que o policial João Mancuso identificou os acusados assim que os viu deixando o local, uma vez que eles já eram conhecidos dos meios policiais. Esse investigador reconheceu os réus de pronto porque já os conhecia. Além disso, o policial João relatou que viu Lucas dispensar as drogas no momento da chegada da polícia." (pgs. 384).

A respeito da citação supra, prudente dizer que é pacífico no âmbito do STF e do STJ o entendimento de ser possível a fundamentação per relationem ou por referência ou por remissão, não se cogitando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal) (E. STF: MS 27350 MC/DF, Relator Min. Celso de Mello, DJ de 04.06.2008; Emb. Decl. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 692.087/DF, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 12.08.2014, unânime, DJe 29.08.2014 e no STJ: REsp 1.426.406/MT, Rel. p/Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11.05.2017).

Em relação aos argumentos defensivos de insuficiência de provas tem-se que o artigo 156 do CPP é claro: "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:"

Com efeito, a dúvida capaz de favorecer os réus deveria estar sustentada em contraprovas e não meramente a partir de argumentações, sob pena de contemplar-se indevidamente a subjetividade e o "decisionismo". As contraprovas incumbem à defesa, na exata dicção do art. 156 do CPP.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 - destaque do Juízo).

A verdade processual obtida vem no sentido de que as acusações ministeriais estão evidenciadas no laudo de exame químico-toxicológico e depoimentos dos policiais empenhados na diligência.

Os réus limitaram-se a negar, o que é esperado diante da garantia extraída do princípio nemo tenetur se detegere.

No que tange à alegada drogadição dos réus, é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, "Ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nadamodifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figura do viciado-traficante" (STF-2ª Turma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou a Colenda Corte Paulista: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

Portanto, este Juízo não se ressentir de dúvida razoável capaz de direcionar sua convicção em sentido oposto à tese constante na denúncia.

Presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade dos réus, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

4 - DO VEREDITO E DOSIMETRIA DAS PENAS

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de págs. 171/173, para CONDENAR LUCAS EDUARDO ARMANDO CAMILLO pela prática do artigo 33, § 4º da Lei

11.343/2006 e WELLINGTON DONIZETE PORTO DA SILVA pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 na forma do artigo 29, caput, do Código Penal, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Em relação ao réu LUCAS:

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

O réu é primário.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não chega a recomendar acréscimo, pois a apreensão limita-se a 23,9 gramas, conforme massa líquida apontada no laudo pericial - pg. 24. Tal quantidade de drogas não pode ser considerada vultosa ou mesmo significativamente maior do que apreensões corriqueiras que vêm ocorrendo nesta comarca e região. Encontra-se, pois, nos "limites do normal" para os casos de tráfico que são analisados neste Juízo.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analizando estes itens o Juízo não encontra campo para ligeiro acréscimo, pois apreendida uma única substância em quantidade pequena.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 no mínimo legal de 5(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

O réu faz jus à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da primariedade e pequena quantidade de drogas apreendida, incapaz de evidenciar ligação a organização criminosa.

Reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 1 (um) ano de 8(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo

vigente à época do fato cada dia-multa.

Inaplicável a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, pois como reconheceu o Parquet, na data dos fatos provavelmente a escola encontrava-se em férias, de modo que a majorante não deve ser aplicada dissociadamente do finalismo penal, contemplando-se simples responsabilidade penal objetiva. A mera proximidade física do estabelecimento escolar não é o bastante para a incidência da majorante que deve guardar relação com a conduta, ou seja, necessário estar evidenciado que os réus valiam-se do equipamento público para facilitar a dispersão dos entorpecentes.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art. 83, V, do Código Penal). Contudo esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Onde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 509.578/SP (2019/0133777-0), STJ, Rel. Antônio Saldanha Palheiro DJe 16.05.2019. Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

Em caso análogo, ao apreciar a apelação nº. 0000032-53.2016.8.26.0613, a Colenda 2ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória proferida por este Juízo, mantendo igualmente a determinação de que o réu inicie o cumprimento da pena sob o regime aberto.

Também a 12ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação nº 0000322-85.2016.8.26.0575 desta comarca manteve o regime inicial aberto com expressa alusão às Súmulas 718 do STF e Súmula 440 do STJ, bem como ao HC STF nº 118.533.

A 16ª Câmara Criminal seguiu o mesmo norte na Apelação nº 0001003-55.2016.8.26.0575 desta Comarca, em acórdão da Relatoria do Eminentíssimo Desembargador Guilherme de Souza Nucci.

Para melhor ilustrar:

TJSP-) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PROFERIDA EM 1º GRAU. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM DESFAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PACIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DA TESE NO SENTIDO DA NÃO HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS, SE PRIVILEGIADO NOS MOLDES DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME ABERTO ESCOLHIDO PELO JUÍZO EM COERÊNCIA À QUANTIDADE DE PENA (01 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO), PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO AGENTE E DEMAIS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO APELO. (Apelação nº 0002209-93.2017.8.26.0438, 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Diniz Fernando. j. 12.11.2018, Publ. 22.11.2018).

TJSP-) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM COMPROVAM A DESTINAÇÃO DO TÓXICO À MERCANCIA E NÃO AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO ACERTADA. QUANTIDADE DAS DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO RÉU QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO E HEDIONDEZ DO CHAMADO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE FOI AFASTADA PELO PLENO DO E. STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E OUTRA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação nº 0000109-82.2018.8.26.0616, 10ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Francisco Bruno. j. 08.11.2018, Publ. 12.11.2018).

TJSP-) TRÁFICO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONDENAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 - CONFIGURAÇÃO - DIMINUIÇÃO DO ACRÉSCIMO. PRIVILÉGIO - SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - MERA ILAÇÃO - QUANTIDADE POUCA EXPRESSIVA DE MACONHA - NEGATIVA INFUNDADA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS - CRITÉRIO - ART. 42 DO MESMO DIPLOMA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO - HEDIONDEZ AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS Nº 118.533. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. (Apelação nº 0003964-83.2015.8.26.0322, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Vico Mañas. j. 05.12.2018, Publ. 07.12.2018).

TJSP-) HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - INSURGÊNCIA CONTRA O REGIME PRISIONAL FECHADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ADMISSIBILIDADE - SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A MOTIVAÇÃO DA R. SENTENÇA, PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90, NÃO SÓ PORQUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECLAROU A - INCONSTITUCIONALIDADE DE TAL DISPOSITIVO, MAS TAMBÉM PORQUE O PRETÓRIO EXCELSO, NO HABEAS CORPUS Nº 118533/MS, AFASTOU A NATUREZA HEDIONDA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO". ALIÁS, HÁ ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO, ACERCA DA NÃO HEDIONDEZ DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO", SEGUIDA POR ESTA COLENDIA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE EFEITO ERGA OMNES OU VINCULANTE DO R. DECISUM DAQUELA CORTE CONSTITUCIONAL, É DE BOM ALVITRE QUE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IGUALDADE, O ENTENDIMENTO EXTERNADO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 118.533 SEJA ADOTADO POR TODOS OS JUÍZES E TRIBUNAIS BRASILEIROS, EVITANDO-SE, COM ISSO, DECISÕES EM SENTIDOS OPOSTOS ACERCA DA MESMA MATÉRIA E QUE SOMENTE AQUELES ACUSADOS QUE POSSUAM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA GALGAR TODAS AS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO SEJAM BENEFICIADOS PELOS EFEITOS DECORRENTES DA NOVA ORIENTAÇÃO DE QUE O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO POSSUI CARÁTER HEDIONDO. DE RESTO, CABÍVEL, EXCEPCIONALMENTE, O REGIME ABERTO EM FACE DO QUANTUM DA PENA E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus nº 2215577-73.2018.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Moreira da Silva. j. 25.10.2018, Publ. 30.10.2018).

TJSP-) PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - INDEFERIMENTO - CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO

- CÁLCULO QUE CONSIDEROU A HEDIONDEZ DO CRIME - INADMISSIBILIDADE - RECENTE JULGAMENTO DO STF QUE ENTENDEU NÃO SER HEDIONDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - HC 118533 - ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ, ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DO STF - SÚMULA 512 DO STJ CANCELADA - NATUREZA HEDIONDA AFASTADA - CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DETENTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - AGRAVO PROVIDO. (Agravado de Execução Penal nº 0013382-10.2018.8.26.0041, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Newton Neves. j. 09.11.2018, Publ. 09.11.2018).

Torno em definitiva a pena supra e afastado o caráter hediondo da conduta fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inviável a substituição da pena, a despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 - SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 - SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que "se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa - e com maior razão."

Para este Juízo não se afigura socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestarem serviços comunitários.

Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

Com efeito, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito.

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

O descumprimento do regime aberto (adequado segundo o STF e STJ), por outro lado, pode prontamente ensejar o encarceramento por regressão ao semi-aberto e, posteriormente, até para o regime fechado.

O réu poderá apelar em liberdade se por all não estiver preso.

Com relação ao réu WELLINGTON:

Na primeira etapa, ratifico a análise anteriormente exposta em relação ao corréu Lucas, pois inexistentes fatores de *discrimen* entre os réus, fixando-se a pena no mínimo legal de 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinzentos) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, este réu era menor de 21 anos à época dos fatos. Todavia, a pena foi fixada no mínimo legal e assim deve permanecer, ex vi da súmula 231 do STJ, de modo que inócua a atenuante.

Diferentemente do correu Lucas, para Wellington é inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que dedica-se a atividades criminosas.

Nas pgs. 182/183 percebe-se que o réu foi condenado por tráfico de drogas em primeiro grau de jurisdição nos autos 1500259-27.2020.8.26.0613 (0000303-49.2021.8.26.0496) por fato ocorrido aos 29.06.2020.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.594.419/RS (2019/0294417-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019).

E ainda: "A teor do entendimento firmado na Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp nº 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14.12.2016, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas." (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.575.466/ES (2019/0264981-9), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 19.11.2019, DJe 03.12.2019)

À minguia de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA a pena de 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa.

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Quanto ao regime prisional afastada a causa de diminuição de pena, permanece o caráter hediondo da conduta a impor o regime inicial FECHADO.

O réu poderá apelar em liberdade se por all não estiver preso, uma vez que não houve decreto de prisão preventiva neste processo.

CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

A cobrança fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do NCPC c.c art. 3º do CPP, pois defiro-lhes os benefícios da assistência judiciária.

Patrocinados por advogados dativos arbitro os honorários, conforme regras do convênio.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeçam-se mandados de prisão, observando-se os regimes iniciais fixados. Os réus deverão ser apresentados para regular audiência de custódia. Quanto ao réu apenado no regime aberto, faculta-se seu comparecimento voluntário em juízo, nos dias úteis, entre 13:00 e 16:30 horas, ocasião em que sua audiência admonitória será "encaixada" na pauta regular, prevenindo-se a intervenção policial para o cumprimento do mandado e eventual intercorrência que possa suceder durante o cumprimento do mandado de prisão;

Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

DECRETO o perdimento do valor apreendido, pois à míngua de sua origem lícita, está evidenciado tratar-se de proveito da traficância desempenhada pelos réus.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA